

1501287-26.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Alexandre Sanches Batagelo

Comarca: Bilac

Foro: Foro de Bilac

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... policiais evidenciam que o réu incidiu na prática de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, corrupção de menor e resistência. Aliás, quanto à validade do depoimento de policiais, confira-se:

"Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bilac

Foro de Bilac

Vara Única

Rua Olavo Bilac, 466, Bilac-SP - cep 16210-000

1501287-26.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501287-26.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alef Henrique Ferreira dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Alexandre Sanches Batagelo

Vistos.

ALEF HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, e artigo 35, todos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), em concurso formal; no artigo 244-B, do ECA, e no artigo 329, caput, do Código Penal; sendo os três primeiros em concurso material com o último, porque, anteriormente e no dia 11.09.2021, por volta das 18:15 horas, na Avenida Francisco Maroni, nº 91, Bairro Chácara Antônio e Borges, na cidade de Piacatu, nesta Comarca de Bilac, juntamente com a adolescente Elen Cristina da Silva Oliveira, associaram-se para fins de comercialização e entrega a consumo de terceiros de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na denúncia que, no dia e horário acima descritos, o denunciado, em conjunto com a adolescente, trazia consigo drogas para fins de tráfico, consistentes em 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, pesando 6,5 gramas, 02 (duas) porções da mesma droga maconha, também embalada por plástico, pesando 48,17 gramas, bem como 73 (setenta e três) unidades de cocaína, pesando 18,73 gramas, prontas para a entrega e consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, as quais são consideradas drogas e são capazes de ensejar a dependência física e psíquica de seus usuários.

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local o denunciado corrompeu a adolescente Elen Cristina da Silva Oliveira, menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando as infrações penais acima mencionadas.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias, o denunciado, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência exercida contra os Policiais Militares Gabriel Stabile Ferreira e Erick Barrense Passos, competentes para executá-lo.

Os Policiais militares receberam denúncia de que no local dos fatos estava ocorrendo a venda de drogas. Dirigiram-se para o local, avistando o denunciado, já conhecido nos meios policiais, com uma porção de droga nas mãos e a quantia de R\$ 10,00 (dez reais), acompanhado da adolescente Elen.

Com a presença dos policiais militares, ALEF dispensou a droga e o dinheiro.

Na abordagem de ambos, os militares encontraram com a adolescente Elen, em uma bolsa que trazia consigo, a quantia de R\$ 4.426,40 (quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) em dinheiro, fruto do comércio ilegal, 73 (setenta e três pedras de crack/cocaína em invólucros plásticos - sendo 26 dentro da embalagem metálica de "mentos" e 47 dentro de um pedaço de saco plástico preto), 01 (um) tablete maior de maconha e 01 (uma) porção menor de maconha, além de um celular marca motorola.

Durante a abordagem, ALEF ofereceu resistência, aplicando violência contra os milicianos, o que foi causa de lesão corporal no Policial Militar Erick.

Diante dos fatos, o indiciado foi preso em flagrante.

É da denúncia, ainda, ser certo o propósito da traficância, haja vista: (1) a natureza, variedade e quantidade de drogas apreendidas, as quais estavam divididas em porções e prontas para a venda a terceiros; (2) a denúncia recebida pelos policiais, no sentido de que no local dos fatos era realizado tráfico de drogas, bem como o fato de ALEF já ser conhecido nos meios policiais; (3) o fato de que, no momento da abordagem, foi apreendida grande quantidade de dinheiro em espécie, fruto do comércio ilícito de entorpecentes.

A existência de uma associação entre o denunciado e sua namorada é igualmente certa.

Por fim, consta ser certo que, ao praticar os crimes juntamente com a adolescente Elen, o denunciado corrompeu a menor.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 12.09.2021 (fls. 79/82).

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado para apresentar defesa preliminar, cuja peça foi juntada às fls. 171/179.

Após afastada a preliminar arguida na defesa, a denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2021 e o feito restou saneado (fls. 183/188 e 192).

Durante a instrução criminal, foram inquiridas duas testemunhas da acusação e duas testemunhas da defesa (fl. 239), sendo o réu interrogado ao final, a pedido da defesa (fl. 240).

Encerrada a instrução (fl. 239), sobrevieram as alegações finais das partes, tendo a acusação pedido a procedência do pedido, entendendo que a materialidade e autoria

restaram comprovadas (fls. 246/254).

A defesa, a seu turno, pugnou pela absolvição do acusado, ante à insuficiência probatória para embasar a condenação e invocou o princípio "in dubio pro reo" (fls. 337/352).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar os delitos de tráfico de entorpecente agravado com fundamento no artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, associação para o tráfico, corrupção de menor e resistência.

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante de fls. 02/03; o auto de apreensão de adolescente de fls. 09/10; o boletim de ocorrência acostado a fls. 12/16; o CPF e a certidão de nascimento da adolescente Elen; o auto de exibição e apreensão de fls. 41/42; a cópia da denúncia anônima recebida pela Polícia Militar; os laudos do Instituto de Criminalística de fls. 47/49, 50/52, 53/55, 108/112, 113/117, 118/122, 129/131, 132/134 e 135/137; os depósitos judiciais de fls. 105/106; o laudo do IML de fl. 73; o laudo médico da testemunha Erick de fl. 125; o relatório da Autoridade Policial de fls. 140/141; os depoimentos das testemunhas e a indigesta negativa de autoria quanto ao tráfico de drogas apresentada pelo acusado em Juízo.

Na Delegacia de Polícia, o acusado permaneceu calado (fl. 11).

Não se quer explorar o silêncio do réu, mas tal passividade não é comum a pessoa que se vê injustamente acusada da prática de um crime.

Nesse sentido:

"Prova silêncio do acusado no interrogatório policial - Valor: - O silêncio do acusado, por ocasião do flagrante, é atitude incompatível com quem se diz inocente, perdendo a oportunidade de esclarecer equívoco de seus acusadores". (Apelação nº 1.268.547/1 - Itanhaém - 15ª Câmara - Relator: Fernando Matallo - 22/11/2001 - V.U. (Voto n.º 4.572))

"PROVA - SILÊNCIO DO RÉU - INTERPRETAÇÃO EM SEU DESFAVOR - POSSIBILIDADE - O fato de o réu ter ficado em silêncio na fase do inquérito policial, posto não se deva tomar por prova plena e cabal de sua culpa, induz a invencível perplexidade quanto à sua inocência, pois repugna a razão deixe alguém de responder aos termos de uma acusação, máxime se inocente." (TACRIMSP - AP 1.045.799 - 15ª C - Rel. Juiz Carlos Biasotti - J. 10.04.1997)

Já em Juízo, o acusado negou a posse e propriedade da droga, afirmando que o entorpecente localizado não era de sua propriedade. Contou que, no dia dos fatos, estava conversando com a adolescente Elen e viu que ela estava na posse de uma "bolsinha", mas não tinha o costume de mexer nas coisas dela. Não é verdade que tenha tentado dispensar algo no momento da abordagem. Estava em frente à sua casa quando viu a viatura policial e não sabia que Elen estava com entorpecentes. Afirmou ostentar passagem por tráfico de drogas, mas estava reabilitado. Negou ter resistido à prisão, mas ter sido agredido pelos policiais. Viu Elen conversando com

uma usuária da cidade, cujo nome não se recorda. Chegou a dizer a Elen para assumir a droga porque ela era menor e seria liberada. O interrogando contou que também é usuário de droga. Nunca viu Elen usando drogas e acredita que ela não usa substância entorpecente. Nunca vendeu drogas tampouco induziu Elen a vender drogas. No momento da abordagem, não estava com nenhuma droga. Nunca usou drogas perto de Elen. Não teve mais contato com Elen após a prisão (fl. 240).

A negativa de autoria apresentada pelo acusado em Juízo restou isolada nos autos e restou contrariada pelas demais provas carreadas aos autos.

A prova dos autos demonstrou a prática de tráfico de drogas por parte do réu, sendo ele, sim, traficante!

A prova oral colhida na instrução trouxe elementos seguros a confirmar a materialidade e autoria dos delitos imputados ao acusado.

No curso da instrução criminal, os fatos inicialmente apurados foram provados através dos documentos constantes dos autos e dos depoimentos prestados em Juízo.

O Policial Militar Gabriel Stábile Ferreira declarou que recebeu denúncia, via COPOM, deslocou-se até o local indicado e presenciou o tráfico. A denúncia feita ao COPOM era rica em detalhes e indicava roupas e bolsa. A denúncia informava que a droga estava dentro de uma bolsa que se encontrava na posse de uma moça e que o réu estaria ao lado dela. Esclareceu que já tinha atendido ocorrência de drogas e arma de fogo envolvendo o acusado anteriormente. De dentro da viatura, os policiais viram o acusado amassar algo que estava em uma das mãos e, na outra, tinha uma nota de R\$ 10,00. O depoente ficou com o acusado a fim de abordá-lo e ele resistiu à abordagem. Durante a abordagem de Alef, a adolescente Elen tentou entrar na casa, mas foi impedida pelo PM Erick, que foi revistar a bolsa, onde localizou droga e dinheiro. Posteriormente, localizaram uma porção de maconha junto com o dinheiro que o acusado amassou. Alef disse aos policiais que a droga era toda dele para consumo próprio. Elen disse que a droga não era dela. Alef já é conhecido nos meios policiais, mas nunca tinha sido abordado porque, quando via a viatura, ele corria. Tomou conhecimento no dia da ocorrência que Elen era namorada de Alef. Na bolsa foram localizados R\$ 4.426,40 em dinheiro, crack e maconha. Enquanto Alef estava sendo abordado e resistia à abordagem, a mãe dele e Elen começaram a xingar e a agredir os policiais. (fl. 239)

No mesmo sentido foi o depoimento do também Policial Militar Erick Barrense Passos: receberam denúncia, via copom, de ocorrência de tráfico e, de posse das características dos envolvidos, foram até o local indicado e realizaram a abordagem. De dentro da viatura, o policial viu o acusado e a adolescente sentados debaixo de uma árvore, próximo à residência do acusado e presenciaram o momento em que Alef, ao perceber a viatura policial se aproximando, amassou algo que tinha nas mãos e jogou perto de uma árvore. Posteriormente, conseguiram localizar dinheiro e maconha que tinham sido dispensados pelo acusado. Elen tentou ingressar na residência quando viu os policiais, mas foi contida pelo depoente. Elen estavam em poder de uma bolsa que continha maconha, aproximadamente 70 pedras de crack, e cerca de R\$ 4.426,00 em dinheiro. Tanto o acusado quanto Elen nada disseram sobre a droga apreendida. Alef ofereceu resistência à prisão, tendo que ser derrubado e contido pelos milicianos. O depoente ficou ferido. Já conhecia o acusado de abordagem anterior. No momento da abordagem, não viu nenhuma pessoa adquirindo drogas do acusado ou da adolescente. Enquanto Alef estava sendo abordado e resistia à abordagem, a mãe dele e Elen começaram a xingar e a agredir os policiais. (fl. 239)

Os relatos dos policiais evidenciam que o réu incidiu na prática de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, corrupção de menor e resistência. Aliás, quanto à validade do depoimento de policiais, confira-se:

“Tóxicos – Tráfico – Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação, ou tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Procedente” (STF – 2a T. – HC n.º 74.522-9/AC – Rel. Min. Maurício Corrêa – DJU 13/12/96, pág. 50.167).

“Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1a Turma – HC n.º 74.608-0 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 11/04/97, pág. 12.189).

A testemunha da defesa Elen Cristina da Silva Oliveira contou que estava com o acusado no momento da abordagem policial. Afirma que estava na posse da bolsa que continha droga e dinheiro, sendo que Alef nada teria a ver com os entorpecentes. A droga era de sua propriedade e estava traficando, mas Alef não sabia. Alef somente tomou conhecimento dos fatos no dia da apreensão. Naquele dia, estavam conversando na frente da casa e combinando de sair com o filho de Alef, momento em que ele entrou na residência para chamar o filho. A depoente, então, viu uma usuária de drogas e fez sinal para que ela não chegasse perto, porque Alef não sabia que a depoente vendia entorpecente. Mesmo assim, a usuária chegou perto e quis comprar entorpecente, mas a depoente se recusou a vender dizendo que ali não era seu ponto de droga e também por conta de Alef. A usuária ficou alterada, momento em que Alef saiu da casa e questionou a depoente e a usuária passou a ameaçar a depoente e Alef, dizendo que faria uma denúncia e foi embora. Ao ser questionada por Alef, a depoente explicou que estava vendendo entorpecente, sendo que Alef disse que ela não precisava disso e que essa vida não a levaria a lugar nenhum. Afirma que não contou a Alef que estava traficando com medo de que ele contasse à mãe da depoente. Reafirma que Alef não estava traficando e não sabia de nada. No dia da apreensão, a droga estava com a depoente e a bolsa também. Alef estava trabalhando. Afirma que é a responsável pelas drogas, pela bolsa e pelo dinheiro apreendido. Quando foi ouvida em seu processo, a depoente não contou a mesma versão dos fatos porque, no momento em que estavam sendo conduzidos à Delegacia de Polícia, Alef disse que não era para a depoente assumir a droga e que seria liberada porque era menor de idade. Alef disse que iria assumir a droga. Em Juízo, a depoente negou os fatos, mas afirma ser a responsável pelas drogas. No momento da abordagem, Alef não tinha drogas com ele, tampouco dispensou drogas e dinheiro. Não foi induzida ao tráfico por Alef porque ele não sabia que a depoente traficava. Foi apreendido um celular que também estava com a depoente. Tanto Alef quanto a depoente foram agredidos durante as abordagens. A mãe de Alef interveio durante a abordagem. Era namorada de Alef há cerca de 05 meses. Seu ponto de tráfico era na frente de sua casa. (fl. 239)

Elen é namorada do acusado e sofreu representação do Ministério Público pela participação na prática dos crimes ora apurados, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de internação (Processo nº 1501288-11.2021.8.26.0076).

A corrupção da adolescente foi tamanha que ela, a todo momento, quando ouvida em Juízo, tenta proteger Alef, dizendo que a droga e a bolsa lhe pertenciam, tudo na tentativa de inocentá-lo.

Sendo namorada de Alef e já tendo sido aplicada a ela medida socioeducativa de internação, é óbvio que tenta proteger o namorado das acusações que lhe são imputadas, até porque ela mesmo negou a propriedade da droga ao ser inquirida no processo por ato infracional.

Já a testemunha da defesa Maria Aparecida Ferreira dos Santos revelou que é genitora do acusado e, no dia dos fatos, quando chegou em casa, Alef estava sendo abordado pelos policiais. Não sabia que seu filho ou Elen tinham drogas. Alef já foi condenado por tráfico, mas, depois disso, nunca mais o viu mexendo com drogas. Alef estava trabalhando em uma fábrica. Elen era namorada de Alef. A bolsa com a droga estava pendurada no pescoço de Elen. Alef foi agredido pelos policiais, mas não agrediu nenhum deles. Não sabia que Elen era traficante. Nunca presenciou pessoas procurando por Alef em sua casa. Não foi apreendida nenhuma droga com Alef. Alef não instigava Elen a traficar. (fl. 239)

Referidas testemunhas, namorada e mãe do acusado, respectivamente, tentaram proteger o réu e seus relatos contradizem os dos dois policiais ouvidos em Juízo e se mostraram isolados nos autos.

Num evidente intuito de proteger o réu e evitar sua responsabilização penal, seus depoimentos devem ser analisados com reserva frente aos depoimentos dos funcionários públicos (policiais militares), depoimentos esses que devem prevalecer sobre o das testemunhas.

Vale mencionar que a denúncia de tráfico havia sido feita via COPOM, com riqueza de detalhes e culminou com a abordagem do acusado e da adolescente. Confirma-se a denúncia no documento de fls. 236/237.

Aliás, o réu já era conhecido nos meios policiais e já havia sido abordado em outras ocasiões por denúncias de tráfico e porte de arma.

A natureza, variedade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do denunciado, já divididos em porções e prontas para a venda a terceiros; a denúncia recebida pelos policiais militares no sentido de que no local dos fatos era realizado tráfico de drogas, bem como o fato de Alef já ser conhecido nos meios policiais; o fato de que, no momento da abordagem, foi apreendida grande quantidade de dinheiro em espécie, fruto do comércio ilícito de entorpecentes, tudo está a caracterizar a traficância perpetrada.

Em casos similares, o entendimento de nossos Tribunais:

“O fato de guardar grande quantidade de erva tóxica, capaz de criar dependência psíquica é, em si, configurador da atividade típica do art. 12 da Lei de Tóxicos (6.368/76). Incabível a desclassificação, ante a impossibilidade de o agente guardar tão significativa quantidade de maconha apenas para seu uso próprio” RJTJRS 76/82).

Existem, portanto, elementos sólidos a embasar o édito condenatório.

Por outro lado, o acusado não trouxe aos autos qualquer prova de sua inocência, nem desconstituiu as provas existentes em seu desfavor.

As substâncias apreendidas consistem realmente em maconha e cocaína (exames químico-toxicológicos de fls. 47/49, 50/52, 53/55, 129/131, 132/134 e 135/137).

Assim, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade

real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal:

“Artigo 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.”

Nesse sentido:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE - CONCEITO - AUTORIA DO DELITO - INDÍCIOS - VALOR PROBANTE - LIVRE CONVENCIMENTO - DEPOIMENTO DE POLICIAL - Entorpecente. Maconha. Tráfico. Autoria. Sistema do livre convencimento. Indícios. Meio de prova. Fato provado e fato probando. Conceito jurídico e noção legal de tráfico de entorpecente. Depoimentos contestes de policiais. Valor e eficácia. Pequenas divergências não são capazes de infirmá-los ou sobre eles gerar dúvidas ou suspeitas. O Juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova e diante do nosso sistema processual o indício é o fato provado que por sua ligação íntima com o fato probando autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Por outro lado, pequenas contradições nos depoimentos de testemunhas policiais, que não afetam no substancial a apuração da verdade, devem ser consideradas como fruto da capacidade de observação de cada um. Ademais, o conceito jurídico de tráfico de entorpecentes, que emerge do texto da Lei n.º 6.368/76, revela-se amplo na medida em que se identifica com cada uma das atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas a que se refere o art. 12 do diploma legal em questão. Disso decorre que a noção legal de tráfico de entorpecente não supõe, necessariamente, que no momento da prisão estivesse o agente na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização. Prova suficiente e capaz de autorizar o juízo de reprovação proposto na exordial acusatória. Provimento do recurso ministerial”. (TJRJ - Acr 803/1999 - (Ac. 21101999) - 1ª C.Crim. - Rel. Des. Paulo L. Ventura - J. 03.08.1999)

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE - FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - A existência de fortes indícios de autoria autoriza a condenação pelo tráfico ilícito de entorpecentes, sendo desnecessária a prova direta do crime”. (TJMG - Acr 000.173.001-9/00 - 3ª C.Crim. - Rel. Des. Roney Oliveira - J. 16.05.2000)

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Prova baseada em depoimentos de policiais. Conteúdo harmônico e seguro admissibilidade. Existência de outros indícios de autoria condenação mantida. Recurso desprovido”. (TJMG - Acr 000.230.863-3/00 - 1ª C.Crim. - Rel. Des. Luiz Carlos Biasutti - J. 28.08.2001)

“ENTORPECENTES - TRÁFICO - MATERIALIDADE COMPROVADA - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA DAS DEMAIS PROVAS - DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS - DROGAS DIVIDIDAS E ACONDICIONADAS EM PAPELOTES - Apreensão de objetos de procedência duvidosa. Indícios evidenciadores da conduta típica. Crime configurado. Condenação mantida. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Incompatibilidade com os rigores da Lei n.º 8.072/90. Benefício indeferido. Regime prisional. Crime equiparado a hediondo. Obrigatoriedade de ser integralmente fechado. Art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90. Súmula criminal n.º 46 do TJMG. Apelos defensivos desprovidos, acolhido, parcialmente, o ministerial”. (TJMG - Acr 000.220.335-4/00 - 1ª C.Crim. - Rel. Des. Zulman Galdino - J. 17.04.2001).

“CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - TRÁFICO - PROVA - PALAVRA DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO - APREENSÃO DO ENTORPECENTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI DE TÓXICOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - Evidenciada a destinação comercial do entorpecente apreendido em poder do

acusado, está caracterizado o delito do art. 12 da Lei n.º 6.368/76, pouco importando não tenha ele sido flagrado no ato da mercancia proibida ou ser pequena a quantidade de droga. Não se demonstrando qualquer eiva nas declarações de policiais, como má-fé ou interesse escuso, seus depoimentos têm valor probante como o de qualquer outra testemunha." (TJSC - ACr 98.014315-2 - SC - 1ª C.Crim. Rel. Des. Paulo Gallotti - J. 22.12.1998)

Não há qualquer motivo para que as testemunhas tentassem acusá-lo falsamente da prática de delito equiparado aos hediondos.

E nem se diga que o réu seria usuário de entorpecentes, até porque a dependência, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. Se o réu é viciado, o ingresso no submundo do crime lhe seria facilitado, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Aliás, repita-se: o uso de drogas, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas.

A propósito, vale aqui mencionar que, mesmo se dizendo usuário de entorpecente, não houve qualquer pedido para realização de exame toxicológico, numa clara demonstração de que a droga encontrada realmente destinava-se ao tráfico.

Ademais, o réu não demonstrou que possuísse renda suficiente para manutenção de eventual vício, vez que não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar seus rendimentos mensais.

O dinheiro apreendido é produto do tráfico.

Nem mesmo a associação para o comércio espúrio de entorpecentes pode ser afastada.

São pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a reiteração ou não jungida e estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33 e 34 da Lei 11.343/06, com dolo específico ou elemento subjetivo do tipo, não havendo, entretanto, necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

Em verdade, é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente, para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal. Ausente um destes requisitos, resta configurada a associação momentânea, regulada na lei penal como concurso de pessoas, tratando-se de uma causa especial de aumento da pena e não um delito autônomo.

Ressalte-se, por oportuno, que não há como tipificar a conduta praticada pelos acusados como uma mera associação eventual, pois tal causa especial de aumento da pena, anteriormente prevista no inciso III, do artigo 18 da antiga Lei de Tóxicos (Lei 6.368/1976), não foi recepcionada pela Lei 11.343/2006, configurando, desta forma a "abolitio criminis". Nesse sentido já se manifestaram os nossos Tribunais:

"Considerando ainda que a nova lei que trata da questão dos tóxicos, n.º 11.343 de 23/08/06 deu abrigo aos termos do antigo art. 14 da Lei 6.368/76, mas não fez o mesmo com a figura da "associação eventual" (art. 18, III), que não mais foi retratada ou tipificada na nova legislação, entendo que não pode mais prevalecer qualquer penalização por conta da figura da associação eventual, que não foi

recepcionada pela nova legislação que combate a disseminação das drogas em nossa sociedade." (TJMG, 1.^a C.Crim., Ap nº 1.0024.06.150183-9/001, Rel. Des. Sérgio Braga, v.u. julg. 15.05.2007; pub. DOMG de 24.05.2007)

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos de sua definição. Neste sentido preleciona Vicente Greco Filho:

"Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..." (GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção - Repressão: Comentários à Lei n.º 10.409/2002 e à parte em vigor da Lei 6368/76 - 12.^a ed. Atual. - São Paulo - Editora Saraiva - 2006 - p. 127.)

Ainda sobre o tema, lecionam Renato Marcão e Guilherme de Souza Nucci:

"Para a forma descrita no caput, exige-se a pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006. É necessário que a associação seja estável; é preciso identificar certa permanência na sociedade criminosa, que não se confunde com mera co-autoria" (MARCÃO, Renato. Tóxicos, 4.^a edição, 2007, São Paulo: Editora Saraiva, p. 281).

"Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.434/2006. É a quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de entorpecentes (...) Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 1.^a edição, 2006, São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 784).

Logo, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira sociedade sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico.

Na espécie, existem elementos sólidos a embasar o édito condenatório. Os depoimentos dos policiais detalharam a participação do acusado e da adolescente Elen Cristina no tráfico de entorpecentes, assumindo cada um deles papel indispensável para possível sucesso em sua empreitada criminosa, com divisão de tarefas.

No caso, o acusado associou-se à adolescente Elen Cristina, de forma organizada e permanente, para vender entorpecentes na cidade de Piacatu.

Nesse contexto, o acusado reuniu-se com Elen Cristina, em caráter de habitualidade e permanência, para o fim de praticarem tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Caracterizada, pois, a sociedade sceleris.

Com relação à corrupção de menores, tem-se que a autoria e a materialidade também restaram devidamente demonstradas.

A prova oral exaustivamente analisada acima comprovou a corrupção da adolescente Elen Cristina por parte do acusado, não havendo dúvidas quanto à participação dela no tráfico e na associação para o tráfico.

Não obstante a negativa do acusado, as demais provas orais colhidas durante a instrução confirmaram a corrupção da adolescente Elen Cristina da Silva Oliveira por parte dele.

Como já dito anteriormente, a adolescente Elen negou que ela e o acusado estivessem traficando entorpecente e que soubesse o que estava acontecendo até chegar na Delegacia, onde foi informada que os policiais haviam localizado drogas na bolsa que estava carregando. Segundo Elen, a bolsa pertencia a Alef e não sabia o que tinha dentro dela. Contou que Alef é usuário de maconha e confessou que também costumava fumar tal droga.

Posteriormente, após lhe ser aplicada medida socioeducativa de internação e quando ouvida na presença do acusado, mudou sua versão dos fatos e assumiu a posse e a propriedade da droga, bem como a prática do tráfico, sem o conhecimento do acusado.

Não há nos autos notícia de que a adolescente já tivesse passagem pela Vara da Infância e Juventude antes dos crimes ora apurados, o que só vem confirmar a ocorrência da corrupção dessa menor pelo acusado.

Ainda que assim não fosse e a menor já tivesse passagens pela Vara da Infância e Juventude, seria caso de condenação do acusado, uma vez que se trata de crime formal e independe de prova da efetiva corrupção da menor, consoante enunciado da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Restou apurado, ainda, que o réu, quando da prisão, desobedeceu à ordem dos policiais e os milicianos precisaram usar de força física moderada para conseguir contê-lo, diante da resistência à abordagem.

Por outro lado, não merece prosperar a alegação de que o acusado tenha sido agredido pelos policiais, vez que, no dia de sua prisão, assinou documento onde o médico legista, Dr. Clewis H. Munhoz Felipe, constatou: "nega agressões, nega lesões, ausência de lesões corporais recentes de interesse médico legal" (fl. 73).

Nenhuma lesão foi constatada no acusado pelo médico legista no momento de sua prisão, o que se mostra incompatível com as alegações de agressão por ele sofridas.

Ao contrário, confirmando o relato dos policiais de que houve resistência à prisão e agressão por parte da genitora e da namorada de Alef, está o receituário médico do policial militar Erick, onde consta que ele sofreu "trauma contuso em face anterior do braço direito, face anterior de perna direita em impressão de tíbia e lesão corto contusa em mucosa oral de lábio inferior, aprox. 1x1 cm" (fl. 125)

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na peça acusatória, o acusado, juntamente com a adolescente Elen Cristina da Silva Oliveira, associaram-se para fins de comercialização e entrega a consumo de terceiros de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; trazia consigo drogas para fins de tráfico, prontas para a entrega e consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; corrompeu a adolescente Elen Cristina da Silva Oliveira, menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando as infrações penais mencionadas; e opôs-se à execução de ato legal, mediante violência exercida contra os Policiais Militares Gabriel Stabile Ferreira e Erick Barrense Passos, competentes para executá-lo.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, no artigo 35, todos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), no artigo 244-B, do ECA, e no artigo 329, caput, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconhecemos a ocorrência dos delitos e passo a aplicar as penas.

O acusado é reincidente específico (fls. 210/211). Por conseguinte, as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhes são favoráveis para efeito de fixação da pena. Deixo, contudo, de elevar a pena-base acima do mínimo legal para não causar bis in idem com a agravante genérica da reincidência.

a) artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Aumento a pena de 1/3 (um terço) em virtude da reincidência específica (06 anos e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 666 dias-multa).

Acresço, ainda, 1/6 (um sexto) à pena em razão da causa de aumento do inciso VI do artigo 40 Lei nº 11.343/2006, considerando que Elen Cristina era menor de 18 anos na data dos fatos, totalizando 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 777 dias-multa, no valor menor.

Não estão preenchidos os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, já que é reincidente específico, demonstrando dedicar-se às atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas há tempo razoável. A forma de acondicionamento das drogas e o envolvimento de adolescente demonstram profissionalismo e inviabilizam a concessão de quaisquer benefícios legais.

b) artigo 35, caput, da Lei 11.343/06:

Fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor menor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Aumento a pena em 1/3 (um terço) em virtude da agravante genérica da reincidência (04 anos de reclusão e pagamento de 933 dias-multa, no valor menor).

Acresço, ainda, 1/6 (um sexto) à pena em razão da causa de aumento do inciso VI do artigo 40 Lei nº 11.343/2006, considerando que Elen Cristina era menor de 18 anos na data dos fatos, o que resulta em 04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 1088 dias-multa, no valor menor.

c) artigo 244-B do ECA:

Fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Aumento a pena em 1/3 (um terço) em virtude da agravante genérica da reincidência, totalizando 01 ano e 04 meses de reclusão.

d) artigo 329 do Código Penal:

Fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Aumento a pena em 1/3 (um terço) em virtude da agravante genérica da reincidência,

o que resulta em 02 meses e 20 dias de reclusão.

Não é caso de se reconhecer o concurso formal entre os crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menor, visto que os desígnios foram autônomos, devendo ser aplicado, portanto, o concurso material.

Observa-se, pois, que, diante dos diferenciados tipos de pena privativa de liberdade (reclusão e detenção), não poderá ser aplicado o concurso material, com a soma das penas. Fixo, assim, cada pena separadamente, observando-se, na fase de execução, o disposto no artigo 69, caput, 2ª parte, do Código Penal.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, diante da gravidade das condutas, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), as penas devem ser cumpridas no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois os dois primeiros são equiparados a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Ademais, a quantidade da pena total, após a aplicação do concurso material, assim como o fato de o réu ser reincidente (inclusive específico quanto ao tráfico), só vem confirmar que o regime deve mesmo ser o fechado.

E nem se diga que o delito de associação não é equiparado aos hediondos. Isso porque, no conceito de tráfico de drogas estão incluídas todas as modalidades de traficância, incluída aquela decorrente de associação. Nesse sentido:

"Habeas corpus - Paciente denunciada como incurso no artigo 35, 'caput', da Lei nº 11.343/06 - Constrangimento ilegal - Ausência de fundamentação no decreto da prisão preventiva - Inocorrência - Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Liberdade provisória - Inadmissibilidade - Crime hediondo - Vedação expressa nos termos do artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.072/90. O argumento utilizado pelos impetrantes de que a paciente é ré primária, portadora de bons antecedentes, que possui residência fixa e família constituída não é fator impedido da custódia cautelar. Excesso de prazo na formação da culpa Constrangimento ilegal - Inocorrência - Instrução criminal encerrada - Aplicabilidade da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça. Ordem denegada." (TJSP - HC nº 1.177.244-3/3-00 - Quarta Câmara Criminal - Comarca Nova Odessa - Voto nº 12.009 - Rel. Des. Salles Abreu, j. 29 de abril de 2008).

No que toca ao delito de resistência, o regime inicial será o semiaberto, mesmo levando em conta a detração penal, haja vista que o acusado é reincidente.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ALEF HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS:

a) ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07), e pagamento de 1865 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), por infração aos artigos 33, caput, e 35, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e ao artigo 244-B do ECA.

b) ao cumprimento da pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 329 do Código Penal.

O apenado, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade, eis que permaneceu preso durante a instrução criminal. Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam sua custódia cautelar, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos, demonstrando periculosidade. Além disso, o acusado é reincidente específico em crime de tráfico e, em liberdade, poderia reiterar conduta já praticada. Nesse aspecto, a ordem pública merece resguardo.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07. Expeça-se mandado de prisão.

Decreto, pois, o perdimento do dinheiro depositado a fls. 105/106, bem como do celular e demais objetos apreendidos (auto de exibição e apreensão de fls. 41/42), com fundamento no artigo 91, inciso II, letra "b" do Código Penal, c.c. arts. 62 e 63 da Lei nº 11.343/06, a serem destinados ao Fundo Nacional Antidrogas, vez que produtos do tráfico.

Deixo de fixar indenização mínima por ausência de parâmetros.

Custas, na forma da Lei.

P. R. I. C.

Bilac, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA